

1524435-27.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" -

Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524435-27.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524435-27.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2276991/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 20750883 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3597/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2276991
- 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDNA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

EDNA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 17h05min, na Rua Helvetia, 28, Santa Cecília, nesta Capital, tinha em depósito, portava e ocultava drogas para tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, disseram as GCMs desta Capital Tatiane Dias do Nascimento e Franciele Cristina da Silva que, na ocasião e local acima indicados, e logo após a limpeza vespertina que à época se fazia pela região conhecida como "cracolândia", acompanhavam a triagem que daí ocorria, momento em que notaram que EDNA, ao avistar a presença da equipe, se esquivou, tentando ir para o lado contrário, a ensinar-

lhes desconfiança.

E daí em seguida a abordando, então, remataram as guardas que dentro da meia que EDNA vestia, encontraram uma (1) pedra de crack, trinta (30) porções individualizadas de "cocaína", e mais quarenta (40) porções individualizadas de "maconha", tudo diante de que ela acusada prontamente lhes admitiu que receberia R\$ 100,00 (cem reais) caso conseguisse entrar no fluxo com a droga, ou seja, admitiu destinação ao tráfico das substâncias.

A ré foi presa em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 55/57.

Pela celeridade processual, o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2021 (fls. 92/94).

A ré foi citada (fls. 112), foi apresentada resposta à acusação (fls. 116/117) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 118).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, após a ré foi interrogada.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a condenação da ré nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Disse que há "causa supralegal de excludente de culpabilidade" pela inexigibilidade de conduta diversa.

Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e fixação de regime mais brando, e o recurso em liberdade (fls. 147/151).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição de apreensão de fls. 11/12 e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/04, bem como pelos laudos de fls. 132/135 e 136/138.

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para cocaína e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 136/138), corroborando o auto de constatação de fls. 132/135.

A autoria do crime pela ré, outrossim, restou demonstrada pela prova oral coligida nos autos.

A ré, na fase inquisitiva, optou por permanecer em silêncio (fls. 07).

Em Juízo, estava na "Cracolândia", usa drogas há 35 anos, já fez tratamento, hoje usa "crack". Estava na "pracinha" e estava usando "crack" e uma pessoa perguntou se não queria R\$100,00 e um grama de droga. Iria pagar para tomar banho. Teria que levar as drogas, atravessar por onde estavam as drogas, ela deveria levar para ele no fluxo. Estava na bota, e as guardas acharam. Morava na rua, há um ano e dois meses. Usa "crack" todo dia. Sobrevive na rua de reciclagem.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A Guarda Civil Municipal Tatiane Dias do Nascimento, reconhecendo A ré em audiência, disse que estava na região da "cracolândia", fazendo a segurança dos agentes da limpeza, após a triagem, a acusada as visualizou e tentou se esquivar. Foi abordada e com ela encontradas as drogas. A limpeza é feita duas vezes por dia e a guarda municipal acompanha. Depois da limpeza as pessoas se movimentam. No retorno se depararam com a ré, que ficou assustada. Ela disse que alguém pediu para ela levar a droga ao fluxo, que lá ganharia dinheiro, R\$100,00. Trabalha no local há bastante tempo, mas não conhecia a ré. Ela disse ser usuária de "crack". No dia revistou somente a ré.

Suas palavras foram ratificadas pelas de sua parceira, a Guarda Civil Franciele Cristina da Silva, que também reconheceu a acusada.

As palavras dos agentes policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação da acusada nos termos da denúncia.

A quantidade de droga encontrada é expressiva e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidos, um total de 30 porções de cocaína (14,9), 1 pedra de crack (55,7g) e 40 porções de Cannabis sativa L (13,9g); sendo capazes de produzir mais de 49 cigarros de "maconha", cerca de 119 fileiras de cocaína e 223 pedras de crack², e assim, suficientes para o comprometimento de um número grande de usuários.

Logo, tudo nestes autos revela que a ré trazia consigo as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) "(TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) "(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Inafastável, assim, a condenação da ré nos termos da denúncia.

Considerando o alegado pelo Dr. Defensor, embora se sinta a situação da ré, que se declara dependente química há anos, não é possível se reconhecer inexigibilidade de conduta diversa.

O vício ou dificuldades financeiras não se configuram como causas de inexigibilidade de conduta diversa, não sendo causa legal de excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade: "A alegação da defesa, de que o apelante Jeferson estaria passando por dificuldades financeiras e precisava do dinheiro, não pode ser acatada, pois, mesmo que comprovadas as dívidas, nada autorizaria lançar-se ao tráfico de 330 quilos de maconha para solvê-las. Deveria, como qualquer pessoa, lançar-se a trabalhos lícitos outros" (TJSP, Apelação Criminal nº 0006373-

82.2015.8.26.0079, Rel. Des. Amaro Thomé, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 22/11/2018, V.U.).

Ainda:

"É impossível aceitar-se a tese do estado de necessidade se o réu podia superar esta circunstância, passando a desenvolver trabalho lícito e honesto, pois a discriminante só pode ser reconhecida em face da presença de perigo atual e inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado, sendo certo que a hipossuficiência e as dificuldades financeiras nunca podem justificar a prática de delitos contra o patrimônio, já que se assim fosse, estaria justificada e legitimada a maioria dos furtos e roubos que ocorrem no Brasil, país pobre e subdesenvolvido" (RJTACRIM 37/143).

Decidida a tipificação, passo a aplicar à ré a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A acusada é reincidente específica (fls. 33/34 e 86/89).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Não há atenuantes a serem reconhecidas.

Pela reincidência específica de rigor a exasperação da pena em 1/6, totalizando cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Deixo, outrossim, de aplicar a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos em razão da reincidência da acusada, sendo a lei bem clara nesse sentido.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR a ré EDNA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena total de cinco anos e dez meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 583 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

A ré não faz jus a qualquer benefício.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que a ré deverá iniciar o cumprimento de sua pena de reclusão em regime fechado, tendo em vista a pena aplicada, a reincidência específica da acusada, a hediondez do delito pelo qual é condenada e a necessidade da prevenção do tráfico de drogas, que se expande cada dia mais com a benevolência dos aplicadores da Lei. Neste sentido:

"Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno social, dê-se que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este Norte. O julgador, portanto, que é agente político, de evidente função social, aplicador da Lei, deve guinar a este sentido, 'data venia'. Daí que aquele que infringe as normas penais, dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive, momento em que sujeita-se, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva. Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Daí que aquele que se dispõe a disseminar entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado. Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais brando, sob pena de violação ao princípio

constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), o que não se pode permitir.” (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

E ainda:

O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos. O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais. Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas. Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave. Mas há os considerados hediondos. Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável. Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado? O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo. A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social. O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados. Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destruir outras sociedades, outras inúmeras famílias. Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa. O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal como procedeu o Legislativo. Bem por isso que a substituição por restritivas de direito é absolutamente inadmissível. Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive! O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de que se trata de crime gravíssimo. Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Em liberdade, ou mesmo em regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!” (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0084044-40.2016.8.26.0050, Relator Desembargador Poças Leitão, São Paulo, negaram provimento, v.u., j. 30/11/2017 - grifei).

E mais, a reincidência da acusada e esta nova condenação indicam nenhum regime menos gravoso é capaz de coibir sua conduta delinquente. Nesse sentido:

“tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal” (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador

Penteado Navarro)

E ainda:

“Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

“Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta” (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário da acusada para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar da ré, ante a manifesta periculosidade que apresenta, a sua reincidência e reiteração criminosa, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se a ré no local em que se encontra presa.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, oficie-se conforme o necessário, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal e extraia-se o DNA do réu para identificação de seu perfil genético, conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

P. R. I. C.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA